



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעים:

1. אפרים גלברג
 2. חנה שינמן
 3. יהודה ענפי
 4. עמית קוזי
 5. נטלי זריהן
 6. ישראל פינקלשטיין
 7. אריאלה אזולאי
 8. נילי שיפ
 9. מיכל רוטברג
- כולם ע"י ב"כ עוה"ד דפנה תמיר
מדרך מנחם בגין 7 רמת גן

- נ ג ד -

הנתבעים:

1. אלון דסטגר
 2. דינה דסטגר
- ע"י ב"כ עוה"ד מימון אביטן
מרחוב ז'בוטינסקי 7 רמת גן

פסק דין

הליך זה עניינו בעבודות בניה שמבצעים הנתבעים בדירתם ובכוש המשותף בבית ברחוב אשרמן 17 תל אביב. עלינו להכריע בהליך זה האם יש למנוע מבעדם להמשיך בביצוע העבודות באופן קבוע או שבידם הזכות כדין, על פי הסכמות בעלי הדירות, להמשיך ולהשלים את הבניה בה החלו.

מבוא וטענות הצדדים

1. התובעים הינם בעלי הזכויות בארבע דירות בבית (תתי חלקות 27, 28, 25 ו-21). הנתבעים הינם בעלי הזכויות בדירה בקומה העליונה בבית (תת חלקה 29).
2. הבית הבנוי על חלקה 39 בגוש 6163 ונרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים.
3. ממסמכי רישום הבית המשותף עולה כי הבית נרשם בפנקס ביחד עם שני בתים נוספים הבנויים על החלקה ועל ניהולו חל התקנון המצוי. הבית המשותף הרישום מורכב מ- 3 מבנים טוריים כאשר הבית דגן ובו 12 דירות (תתי חלקות 19 עד 30) הינו חלק ממנו.
4. התובעים טוענים כי הנתבעים החלו לבצע עבודות בבית הכוללות שינויים פנימיים בדירה על ידי הפיכת אחד החדרים לממ"ד, הגבהת גג הרעפים ושימוש בחלל גג הרעפים כולל



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מרפסת גג ומדרגות פנימיות לעליית הגג ולמרפסת. העבודות החלו מבוצעות בצורה רשלנית תוך גרימת נזקים לדירת התובעים 4-5. לבד מכך הרי שהבניה המבוקשת בעליית הגג וחזקת החדר בדירת התובעים מסוכנת ופוגעת באופן משמעותי ביציבות הבית. בידי התובעים אין הסכמות מפורשות של 75% בעלי הדירות לביצוע העבודות וזאת כאשר דבר התנגדות בעלי הדירות ידוע לנתבעים לאור התנגדויות שהוגשו בהליך התכנוני על ידי 7 מבעלי הדירות בבית. די בהתנגדות התובעים (בעלים של 4 דירות בבית) לשלול את אפשרות התובעים לבצע את הבניה המבוקשת. ההרחבה המבוקשת מסכלת אפשרות למימוש זכויות על פי תמ"א 38 ובהתאם ניתן זמן לצדדים, במסגרת הליכי הרישוי, למצות הליכי תמ"א. דא עקא, הנתבעים מכשילים מאמצים אלו. מדובר בפגיעה מהותית בזכויות בעלי הדירות. התכנון והבניה מנוגדים לפסק דין לפיו נאסר על הנתבעים שימוש בשטח הגג (תיק 51/13 ו- 50/13).

5. בכתב ההגנה נטען כי טענות התובעים לעניין הבניה הועלו במסגרת הליכי התכנון ונדחו. הכרעות אלו חלוטות ואין להיזקק לטענות בשנית. כל התובעים הסכימו לבנייה המבוקשת - התובעים 5-9 ידעו בדבר כוונת הנתבעים לבצע הבניה המתוכננת ואף השכירו לנתבעים את דירתם למשך תקופת הבניה. התובע 1 היה מודע להליכים והציע את הסיוע ההנדסי ללא כל התנגדות לעצם הבניה. התובעים 3, 4 ו- 5 לא התנגדו גם הם לכל היבט למעט בכל הקשור לסוגיה ההנדסית. דירת התובעים 4 ו- 5 הורחבה ולפיכך הם אינם זכאים להתנגד להרחבה דומה. 8 בעלי דירות נתנו הסכמה פוזיטיבית לביצוע ההרחבה ולאור העובדה כי מבוצעות עבודות מיגון בדירה די ברוב זה על פי הדין כדי לאשר את הבנייה. התובעים נתנו את הסכמתם לבניה באמצעות ב"כ עו"ד ישעיה ירון במסגרת הליכי התכנון ולא ניתן על פי הדין והצדק לאפשר להם לחזור בהם מהסכמתם. אין כל התנגדות לביצוע פרויקט תמ"א 38 לאור הסכם התקשרות עם יזם פינוי בינוי וממילא אין בבנייה המבוקשת למנוע ביצוע פרויקט תמ"א 38, שכן הבניה מבוצעת ללא חזקת הבית. העיכוב בבנייה גורם לנתבעים לנזקים משמעותיים ומאידך לא נגרמו ולא ייגרמו כל נזקים כתוצאה מהבניה. מוכחות כל הטענות שעניינן סכנה ליציבות המבנה, מה גם שמדובר בבנייה נפוצה בשכונה. ההתנגדות לבניה הינה בחוסר תום לב והתביעה הוגשה בשיהוי ניכר, לאחר שנגרמו נזקים משמעותיים לנתבעים.

6. אזכיר כי תחילתו של ההליך בבקשה למתן צו מניעה זמני במעמד צד אחד (תיק 98/14). לאחר דיון במעמד הצדדים ניתן צו מניעה זמני עד להכרעה בתובענה בהחלטתי מיום 27.02.14.

הרקע המשפטי

7. מסגרת הדיון המשפטי בהליך דנן עניינה בסימן 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט - 1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הידוע גם כ"תיקון 18" לחוק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

8. הכלל הקבוע בחוק המקרקעין הוא כי על מנת לעשות שימוש ייחודי ברכוש משותף יש צורך בקבלת הסכמה של כל בעלי הדירות בבית משותף - סעיף 62(א) לחוק המקרקעין קובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות". כך גם קובע סעיף 12(ב) לתקנון המצוי כי החלטה המשנה את זכויותיו של בעל דירה לא תהיה לה תוקף כלפיו, אלא אם אותו בעל דירה הסכים לה. משמעות הסעיף האמור, גם היא, כי נדרשת הסכמה של כל בעלי הדירות כדי לשנות זכויות קנייניות של בעלי הדירות בבית.

9. תיקון 18 לחוק המקרקעין מהווה חריג חקיקתי לכלל זה.

כך קובע סעיף 71(א) לחוק המקרקעין כי: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

10. בהתאם להלכות שנפסקו עם השנים הרי שההסכמה של בעלי הדירות (כולם או 3/4 מהם או 60% מהם, בהתאם לנסיבות כאמור) לכל גריעה מהרכוש המשותף והצמדתו לדירה מסוימת צריכה להיות מפורשת (רע"א 259/99 חב' פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב פ"ד נה(3) 385, 402 ולסקירת הפסיקה בנדון גם ע"א (מחוזי חי') 1677/05 כרמל נ' ינקוביצי (פורסם בנבו)).

הסכמה כנ"ל יכולה להינתן גם בעל פה. אולם, במקרה שכזה עליה להיות מוכחת בראיות מספיקות (עא (מחוזי ת"א) 2360/07 אילן הורוביץ נ' גיא נחמני (פורסם בנבו), ע"א 188/76 רוזנוקס נ' הוטר, פ"ד לא(1) 382, ע"א 815/81 כליפא נ' שאול, פ"ד לו(3) 78 וכן ת"א (חי') 744/05 יואלס נ' אידלברג (פורסם בנבו)).

11. יוצא, אם כן, כי המחוקק התיר בחקיקה ספציפית פגיעה מסויימת בזכויות הקניין של בעלי דירות בבית משותף - חלק הסכמה של כל בעלי הדירות להצמדה של חלקים מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה פלונית, קבע המחוקק, כאמור, רף נמוך יותר של הסכמת 3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף לצורך הרחבת דירה או הסכמה של 60% מבעלי הדירות כדי להכשיר בניית ממ"ד או ממ"ק.

האם בידי הנתבעים הרוב הנדרש לביצוע עבודות ההרחבה

מהו הרוב הנדרש לביצוע הבניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

12. ממסמכי הרישוי והבקשה להיתר שהוגשו על ידי הנתבעים עולה כי הבניה המבוקשת כוללת הריסת גג הרעפים, הגבהת חלל גג הרעפים, בניה של חדר על הגג עם מדרגות פנימיות בשטח של 48.47 מ"ר, ושיפור מיגון לחדר בדירה הקיימת בשטח של 12.26 מ"ר (ר' תשריט ההיתר בנספח 1 לתצהיר ענפי והיתר בניה בנספח 12 לתצהיר הנתבע).

13. אף אם נראה בשיפור המיגון המבוקש כ"מרחב מוגן דירתי" כהגדרתו בחוק המקרקעין, אין ברכיב בקשה זה להפוך את הבקשה להיתר בכללותה לכזו הקשורה בבניית מרחב מוגן דירתי. ברי כי בניה הכוללת הריסת והגבהת גג הרעפים ובניה של חדר בחלל הגג, איננה קשורה בהכרח לשיפור המיגון ומהווה אך תוספת בגדר "הרחבת אותה דירה". מכל מקום, תכנונית אין מדובר בבניית "ממ"ד" אלא בחיזוק חדר בלבד.

בפרט אמורים הדברים כאשר שיפור המיגון מבוצע בתוך שטח דירת הנתבעים הקיים וממילא הוראות תיקון 18 אינן חלות בנוגע לבניה זו - השטחים המשותפים וזכויות הבניה עניינם בחדר אשר מבוקש לבנות בחלל גג הרעפים.

14. לאור האמור הרי שבכדי לאשר את הבניה המבוקשת בחלל הגג על הנתבעים להוכיח כי בידם הסכמות של 3/4 מבעלי הדירות שלדירותיהם צמודים 2/3 מהרכוש המשותף (בהתאם לסעיף 71ב(א) רישא לחוק).

15. ובהקשר זה יודגש, מי שמעוניין להרחיב את דירתו על חשבון הרכוש המשותף בבית מבקש, למעשה, לגרוע מזכויות הקניין של בעלי הדירות האחרים בבית, ובהתאם לתיקון 18 לחוק המקרקעין, אפשרי הדבר בהסכמת רוב מסוים, כחריג לכללי הקניין הרגילים כאמור. לפיכך, עליו האחריות לקבל את ההסכמות הנדרשות ברוב המתאים ועליו גם הנטל להוכיח כי הסכמות אלו נתקבלו.

16. בכך גם תומכת העובדה כי על פי מסמכי רישום הבית המשותף (המצויים בידיעתי השיפוטית) אין חלל הגג צמוד לדירת הנתבעים וגם לא מוקנות להם בתקנון (המצוי) זכויות הבנייה הנדרשות לביצוע העבודות המבוקשות. גם פסק הדין בתיק 50/13, בהליך שבין הנציגות לנתבעים (על יסוד הסכם פשרה בין הצדדים), תומך באמור (נספח 3 לתצהיר זריהן).

17. לאור העובדה כי בבית 12 דירות וחלקה של כל דירה ברכוש המשותף זהה (1/48 חלקים בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף), הרי שעל הנתבעים להוכיח כי בידם הסכמות של לפחות 9 מבין בעלי הדירות בבית.

18. הנתבעים טוענים כי כל בעלי הדירות נתנו הסכמתם לבניה (במפורש או במשתמע) ואינם יכולים לחזור בהם מהסכמתם וכי המתנגדים היחידים, למעשה, הינם התובעים 4 ו-5 (עמוד 38 שורה 13). מאידך, על פני הדברים, התובעים הינם בעלים של 4 מתוך 12 הדירות בבית וללא הסכמתם, אף אם התקבלו הסכמות של כל בעלי הדירות האחרים, הרי שאין בידי הנתבעים את הרוב הנדרש לביצוע העבודות. גם הנתבע מאשר כי בידו רק 8 הסכמות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מפורשות בכתב (עמוד 37 שורה 16). משכך, למען יעילות הדיון נבחן תחילה האם ניתנה הסכמת התובעים לבניה. ככל שזו לא ניתנה הרי שיתירת הצורך בבדיקת ההסכמות של מי מבעלי הדירות שאינם בין הצדדים להליך זה.

בחינת ההסכמות

הסכמת התובעים 1 ו- 2

19. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים וראיותיהם אני קובע כי לא ניתנה הסכמה קניינית של התובעים 1 ו- 2 לבנייה המבוקשת.

20. ראשית, אין כל תיעוד, ולמעשה גם לא כל טענה, כי הנ"ל חתמו על הסכמה לביצוע הבניה, בין בטופס החתמת שכנים על גבי הבקשה להיתר ובין בכל דרך אחרת. עדות התובע 1 בהקשר זה לא נסתרה (סעיף 4 לתצהיר ועמוד 24 שורה 3). אין כל ראיה, וממילא לא כל טענה, בדבר הסכמה, בכל דרך שהיא, של התובעת 2 לבקשה להיתר.

21. שנית, אין כל ראיה בדבר קיומה של הסכמה בעל פה וגם לא עלתה כל טענה בדבר קיומה של הסכמה שכזו.

22. שלישית, מעבר לכך שנדרשת הסכמה מפורשת בהתאם להוראות תיקון 18 כאמור לעיל ואין די בהסקת קיומה של הסכמה מכללל לשם תחולת החוק, הרי שבנסיבות דנן גם הסכמה מכללל לא הוכחה - מכתב התובע 1 (נספח 14 לתצהיר הנתבע) אינו מלמד על קיומה של הסכמה, לא תכנונית ובודאי שלא קניינית (סוגיה שכלל איננה נזכרת במכתב ואיננה קשורה לתוכנו). כך גם מעיד התובע 1 - אין במכתב לא הסכמה לבניה וגם לא התנגדות לה (עמוד 23 שורות 1-4). המכתב גם נשלח עוד בטרם נודע לתובע בדבר הבניה המתוכננת ומשכך לא ניתן להסיק הסכמה מודעת, במועד משלוח המכתב, בהעדר ידיעה פרטנית מהי אותה הבניה המבוקשת (עמוד 23 שורות 22-29).

23. התובעים הנ"ל גם התנגדו לבקשה להיתר במסגרת הליכי התכנון - התנגדות אשר שוללת, כשלעצמה, קיומה של הסכמה מכללל (ודאי בשלב הליכי התכנון).

24. רביעית, בתצהירו טוען הנתבע כי לו היה התובע טוען במכתבו הנ"ל כי הוא מתנגד לבניה הרי שהיה שוקל את צעדיו (סעיף 47 לתצהיר). דא עקא, אין כל הסבר מדוע לא טרח הנתבע לפנות לתובעים 1 ו- 2 ולקבל את הסכמתם המפורשת, בין לפני נקיטת הליכי התכנון, בין לאור ולאחר התנגדותם התכנונית, ובפרט לאור המכתב האמור ופרשנות הנתבע את אותו המכתב. מדובר בהתנהלות בחוסר תום לב של הנתבע או למצער בעצימת עיניים שדי בה לשלול כל טענה בדבר קיומה של הסכמה מכללל. ויוער, הנתבעים היו מיוצגים משלב מוקדם, עוד במסגרת הליכי התכנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

25. חמישית, אומנם אין כל מכתב מטעם התובעים הנ"ל במסגרתו הם מתנגדים לבניה והתנגדותם גם לא הועלתה בעל פה (עמוד 24 שורה 1). אולם, הנטל על הנתבעים הוא להוכיח קיומה של הסכמה מפורשת כאמור ואין די ב"העדר התנגדות" כדי לבסס תנאי הסכמה שכזו.

הסכמת התובע 3

26. לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של הסכמה של התובע 3 לבנייה המבוקשת.

27. ראשית, אין כל ראיה בדבר קיומה של הסכמה בכתב של התובע 3 לבנייה המבוקשת. אין גם כל ראיה או טענה לקיומה של הסכמה בעל פה. למעשה, הוכח כי בין הנתבעים לתובע 3 נתק משמעותי ללא כל תקשורת (ר' למשל עמוד 13 שורות 15-16 ועמוד 15 שורות 21-22).

28. שנית, אין כל יסוד למסקנה בדבר קיומה של הסכמה מכללל (שממילא אין בה די).

התובע 3 התנגד לבקשה להיתר ואף נכח בדיון ההתנגדויות (עמוד 12 שורה 5). הודעת דוא"ל של התובע 3 (מוצג נ/1) איננה מלמדת על קיומה של כל הסכמה, לא תכנונית ולא קניינית. למעשה, עולה מהתכתבות זו דווקא התנגדות מפורשת לאור התכנון בנוגע ל-"פניה למפקחת" כנגד הנתבעים.

גם מערכת היחסים שבין התובע 3 לנתבעים, כפי שמתוארת בעדותו, איננה מאפשרת הסקת מסקנה כלשהי בדבר קיומה של הסכמה מכללל - "הוא לא היה מוכן לדבר הוא איים עלי הוא שלח לי מייל שהמיילים שלי נזרקים לפחי והגיש עלי תלונה במשטרה. אני יכול להציג את התכתובת הזו. ש.ת. אני מנסה להתכתב עם אלון. אני פונה אליו בבקשה להיפגש, הוא עונה לי שהוא ישלח את זה למשטרה. ש.ת. אני אראה לך מה רלוונטי במה שכתבתי. אני הוצאתי מייל "אלון שלום, נשמח לשבת איתך וללבן את כל הסוגיות שעדיין מועלות על ידך ובלא תנאים מוקדמים" ש.ת. לא הלכנו לאף עו"ד על להליך הזה. ש.ת. אחרי שאלון הגיש תלונה כנגדי במשטרה כמטריד אינני מוצא כל יכולת להמשיך תקשורת איתו" (עמוד 13 שורות 15-22). למעשה, מן ההתכתבות המצוטטת בעדות יכול וצריך היה הנתבע (ודאי כאשר הוא מיוצג על ידי עורך דין) להבין כי אין בידו את הסכמתו הקניינית של התובע 3.

כך גם עדותו של התובע 3 בכל הקשור להידברות שבין הצדדים, ובפרט, בכל הקשור למכתבו לעירייה, מלמדת על התנגדות לבניה - "עשינו הערכה, אני עשיתי הערכה, ישבנו יחד עם אפרים עם נטלי והבנו שיש פה צעד אחד בכיוון של היתר לבנייה אבל מתוך הבנה שלא יעלה על הדעת שהבנייה תעשה בלי שהגיעו להסכמות מיקדנו את הפעילות הנוספת בבנייה שאני עשיתי אחרי ניסיון שלא צלח להגיע לשיחה עם הנתבע והוא איים ביקשתי להיפגש איתו הוא התלונן נגדי כמטריד ביקשתי מאפרים שהוא מהנדס בניין שילך אליו שינסה הוא לדבר איתו זה לא צלח הוא לא היה מוכן לדבר איתו. אז ביקשתי מאפרים לנסח מכתב בנוגע לסוגיות שהטרידו אותנו ליציבות את המכתב שלחתי לעירייה ובחודש ספטמבר קיבלתי תשובה על התניות שקיימות בחוק לגבי הנושא של הבנייה מאותה



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

תקופה, ספטמבר עשינו בדיקה בחודש ינואר וקיוונו שעל אף כל ההתנהלות הקלוקלת הנתבע לא יעז להתחיל בבניה לא שהוא השלים את ההסכמות הנדרשות וישב אתנו על המשמעויות שלהם" (עמוד 13 שורות 9-1).

29. שלישית, על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר בעבר הנתבעים החתימו את התובע 3 בפועל על הסכמתו לבנייה בדירה אחרת בבית והיו מודעים לצורך בקבלת הסכמתו וחתימתו הברורה (עמוד 13 שורות 24-30).

30. רביעית, אומנם, לא נשלחו הודעות בכתב מטעם התובע בדבר העדר הסכמתו (עמוד 13 שורה 23). אולם, משלוח הודעה שכזו אינו נדרש מבעל דירה אשר מתנגד לביצוע פעולות ברכוש המשותף. ודאי אמורים הדברים בנסיבות בהן בעל הדירה שלא נתן את הסכמתו גם מודע לכך כי אין בידי המבקשים לבנות את מכסת ההסכמות הנדרשות על פי דין (עמוד 10 שורות 13-14).

הסכמת התובעים 4 ו-5

31. לא עלה בידי התובעים להוכיח הסכמת התובעים הנ"ל לבניה המבוקשת.

32. ראשית, אין כל טענה או ראיה בדבר קיומה של הסכמה בכתב או בעל פה. למעשה, מעדות הנתבע עולה כי התובעים הנ"ל הם המתנגדים המשמעותיים איתם הנתבעים מצויים בסכסוך (עמוד 38 שורה 13). הנתבע גם מאשר במפורש כי אין הוא מסתמך על הסכמה ישירה כלשהי של התובעים הנ"ל (עמוד 38 שורה 28).

33. שנית, "מערכת היחסים" שבין התובעים הנ"ל לנתבעים קשה, בלשון המעטה וכוללת תביעות משפטיות, תלונות במשטרה והאשמות (פליליות ואזרחיות) אחרות. למעשה, אין כל קשר בין הצדדים (ר' עדות קוזי בעמוד 25 שורות 25-28, בעמוד 26 שורות 1-23 ובעמוד 28 שורות 5-7, עדות זריהן בעמוד 29 שורות 6-12 ובעמוד 30 שורות 5-7 ועדות הנתבע בעמוד 38 שורות 26-27). בנסיבות הקשות המתוארות לא ניתן לקבל את טענת הנתבעים כי סברו שבידם הסכמה משתמעת או מכללא בדרך כלשהי מצידם של התובעים הנ"ל. דווקא בשל קיומן של מחלוקות אלו היה על הנתבעים לדאוג לקבלת הסכמה כתובה, ברורה ומפורשת.

34. שלישית, אומנם, התובעים לא שלחו לנתבעים הודעה בדבר התנגדותם, אך אין זו חובתם על פי דין. כאמור, הנטל הוא על הנתבעים לקבל את ההסכמות הנדרשות לבנייה. עדותה של זריהן בהקשר זה מקובלת עליי – "אין לי ראיה בכתב לאלון על (צ"ל, אל, א.ס.) תבנה אין לך מספיק הסכמות. אם אתה לא עדכנת אותו שאין לו את הרוב הקנייני זה בעיה שלכם. ש.ת. התנגדנו מבחינה בטיחותית של המבנה, תמ"א 38 או כל פרוייקט אחר. מבחינה קניינית הוא היה מלווה כל הזמן על ידך. ש.ת. לא הודעתי לך שאני מתנגדת. זו זכות קניינית שלי. זה חוק" (עמוד 30 שורות 24-28).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

35. רביעית, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח קיומה של הסכמת התובעים 4 ו-5 מכח הוראת סעיף 71ב(ג) לחוק המקרקעין. לבד מטענה כללית בתצהיר הנתבע (סעיף 77 לתצהיר) לא הובאה כל ראיה בדבר ההרחבה האמורה - לא תמונה, לא תשריט, לא היתר ולא חוות דעת. ודאי אמורים הדברים כאשר לצורך הסתמכות על הוראת החוק האמורה על הנתבעים להוכיח קיומה של "הרחבה דומה" ואין די בהכרח בכל הרחבה שהיא. התובעים אף לא נשאלו בהקשר זה במסגרת חקירתם הנגדית.

36. חמישית, בכל הקשור לטענה בדבר הסכמת התובעים 4 ו-5 (ובכלל האמור גם כל שאר בעלי הדירות) באמצעות עו"ד ירון במסגרת דיון ההתנגדויות נתייחס להלן.

הסכמת התובעים 6 עד 9

37. לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי ניתנה הסכמת התובעים הנ"ל לבנייה המבוקשת.

38. ראשית, גם בנוגע לתובעים האמורים אין כל טענה בדבר קיומה של הסכמה בכתב או בעל פה לבנייה המבוקשת וממילא לא כל ראיה. כל טענות הנתבעים להסכמת התובעים הנ"ל עניינן בהסקת הסכמה מכלל (מכח השכרת דירתם לנתבעים לתקופה קצובה) שאין בה די לביסוס ההסכמה הנדרשת לצורך בניה על פי תיקון 18 לחוק כאמור לעיל.

39. שנית, אין כל אזכור לעבודות הבניה בהסכם השכירות (נספח 8 לכתב ההגנה) ולא בכל מסמך אחר. אם אכן הסתמכו הנתבעים על הסכמת התובעים לבנייה, וזו ניתנה, והיה גם ידוע וברור לצדדים (כגרסת הנתבע בעמוד 38 שורות 1-3) כי השכרת הדירה הינה עבור צורך זה, הרי שאין כל הסבר מדוע לא ניתן ביטוי בכתב בדרך כלשהי להסכמה זו, ודאי כאשר ישנה גם התקשרות חוזית בין הצדדים. בפרט אמורים הדברים כאשר הנתבעים היו מודעים לכך שהתובעים הנ"ל - המשכירים, לא נתנו את הסכמתם לבקשה להיתר (עמוד 38 שורה 4).

40. שלישית, מקובלת עלי עדותו של מר שיף כי הנתבעים ביקשו לשכור את דירת התובעים בשל עבודות שיפוץ בדירתם וכי לא הודיעו בדבר כוונתם לבצע גם עבודות ההרחבה בגג הבית (עמוד 31 שורה 29 עד עמוד 32 שורה 2 וכן שורות 8-10). בהקשר זה אזכיר כי מדובר בעד אובייקטיבי מטעמים של הנתבעים. עדות זו נתמכת גם בעדות קוזי (עמוד 26 שורות 24-27), עדות ענפי (עמוד 14 שורות 24-29) ועדות זריהן (עמוד 30 שורות 15-19).

ודאי אמורים הדברים כאשר ברקע קיים פסק הדין בהליך קודם בין הנציגות לנתבעים (תיק 50/13) כפי שמעיד מר שיף - "הוא אמר לי אני משפץ נקודה. באותה תקופה היה בפני הסכם הפשרה בין הדיירים שלפיו אלון יורד מהגג מחזיר את המפתחות לוועד ואף אחד לא רשאי לעשות שימוש בגג. אני הבנתי שכשהוא אמר משפץ זה את הבית שלו וזו זכותו" (עמוד 32 שורות 3-5).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

41. רביעית, מעדות שיף עולה כי השכרת הדירה אושרה רק לתקופת השיפוץ בדירת הנתבעים - "שוחחתי עם אבא של אשתי. אמרתי שהוא לא בונה אלא משפץ והוא הסכים להשכיר לו את הדירה" (עמוד 32 שורות 1-2). זאת כאשר התובעים הנ"ל גם התנגדו בהליך התכנוני (עמוד 32 שורה 15).

42. חמישית, יש גם לזכור כי התנהלות הנתבעים בנוגע להשכרת הדירה היתה מול מר שיף בלבד. אין בקשר הישיר שבין התובעים הנ"ל לבין הנתבעים כל מוטיב של הסכמה - לא בהסכם השכירות, לא באי חתימתם על הבקשה להיתר ולא בהגשת התנגדותם לוועדה המקומית.

האם ניתנה הסכמה לבניה בדיון ההתנגדויות

43. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים לפיה ניתנה הסכמת בעלי הדירות, כולם או חלקם, לבניה המתוכננת במסגרת טיעוניו של עו"ד ישעיה ירון בדיון בהתנגדויות מיום 25.07.12 (נספח 5 לתצהיר הנתבע). ויודגש, בהקשר זה מדובר, למעשה, בטענה בדבר הסכמה בעל פה אשר מחייבת הצגת ראיות ברורות וחד משמעיות לקיומה של אותה הסכמה – ראיות כאלו אין.

44. ראשית, הוכח בפני כי המסמך עליו מסתמכים הנתבעים אינו פרוטוקול מילולי מדויק - מדובר במסמך שכותרתו "תיאור דיון" ואין המסמך גופו מתיימר לשקף את כל אשר נטען או נאמר במסגרת הדיון, כפרוטוקול בהליך שיפוטי. בהקשר זה מקובלת עלי עדותו של עו"ד ירון (עמוד 17 שורות 8-14), שלא נסתרה בכל עדות אובייקטיבית נגדית, למשל, באמצעות תעודת עובד ציבור מטעם נציג הוועדה המקומית או עורך המסמך. הוכח בפני גם כי לא כל מה שנאמר על ידי הנוכחים נרשם ולמעלה מכך, היו דוברים שטיעוניהם ועצם העובדה כי נשאו דברים בדיון כלל לא נזכרו (ר' למשל עדות ענפי בעמוד 11 שורות 28-30 ועמוד 12 שורה 5 וכן עדות עו"ד ירון בעמוד 17 שורות 13-14, 19 ו-27-29). בנסיבות אלו לא ניתן להסתמך על הכתוב במסמך ככזה המתאר במדויק את אמירות והסכמות הצדדים.

45. שנית, לא ניתן להסיק מטיעוני עו"ד ירון בדיון כי ניתנת לנתבעים הסכמה קניינית לביצוע העבודות – מדובר בהליך תכנוני ולכל היותר, אף אם ניתן לראות בדבריו הסכמה כלשהי, הרי שהיא בהקשר זה בלבד. לא ניתן לנתק את מסמך "תיאור הדיון", שאינו ציטוט ותיעוד מדויק כאמור, מההקשר הכללי שלו - דיון בהתנגדויות.

46. שלישית, הדברים האמורים מקבלים משנה חיזוק שעה שאפילו במסמך תיאור הדיון נרשם במפורש טיעון עו"ד ירון לפיו "אין הסכמה של רוב הדיירים להגשת הבקשה". מקובלת עלי גם עדותו של עו"ד ירון, שלא נסתרה, כי במסגרת הדיון הוא גם טען בדבר הצורך בעריכת הסכם מסודר עם שמאי בטרם הוצאת היתר בניה (עמוד 17 שורה 27 עד עמוד 18 שורה 2). טענות אלו, כשלעצמן, אינן משתלבות עם טענת הנתבעים בדבר קיומה של הסכמה קניינית בעל פה לבניה המבוקשת במעמד הדיון בהתנגדויות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

47. רביעית, אף אם היינו מקבלים את פרשנות הנתבעים למסמך האמור הרי שלכל היותר הסכים עו"ד ירון, גם לשיטת הנתבעים, כי יאפשר בניה אם נושא התמ"א לא יקודם. דא עקא, אין מדובר, על פניה, בהתחייבות חד משמעית והחלטית שאיננה מחייבת הסכמה נוספת בהיבט הקנייני. מן העדויות עולה כי בעלי הדירות עוד מקדמים הליכי תמ"א 38 בבית (ר') למשל בעדות הנתבע עצמו בעמוד 39 שורות 2-5). מדובר, לכל היותר, בהסכמה מותנית אשר הנתבעים כלל לא פעלו להביא למימושה - "לא הודעתי לאנשים שהתנאי מומש וההסכמה שלהם נכנסת לתוקף אחרי שקיבלתי את ההיתר" (עמוד 38 שורה 5).

48. חמישית, הוכח בפני כי עו"ד ירון לא ייצג את כל המתנגדים בהליך ולכל היותר ייצג את התובעים 4 ו-5 ולמצער את נציגות הבית. בהקשר זה לא ניתן יפוי כח מטעם המתנגדים לייצוגם על ידי עו"ד ירון (עמוד 18 שורות 8-9) ולא הוצג כל יפוי כח כנ"ל. עו"ד ירון מעיד כי ייצג את התובעים 4 ו-5 וגם ההתנגדות שהוגשה על ידו מנוסחת בהתאם (נספח 1 לתצהירו). אין כל כתב התנגדות נוסף מטעם מי מהמתנגדים (למעט התובעים 4 ו-5) אשר הוגש על ידי עו"ד ירון.

עדויות של עו"ד ירון נתמכת גם עדויות דנוס (עמוד 20 שורות 28-29), קוזי (עמוד 27 שורה 8 ושורה 27) וזריהן (עמוד 28 שורה 21 ועמוד 29 שורות 2-3). גם מעדות ענפי עולה כי הוגשו התנגדויות פרטניות על ידי בעלי הדירות והנציגות (עמוד 11 שורות 9-17).

49. שיטת, אף אם עו"ד ירון ייצג את נציגות הבית הרי שאין בכך לסייע ביד הנתבעים - במסגרת הליך זה הוכחה, לכל היותר, הסמכה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות את הנציגות להגשת התנגדות תכנונית (ר' נספח 1 לכתב ההגנה). אין כל הסמכה למתן הסכמה קניינית או כל הסכמה אחרת. מכל מקום, כאמור לעיל, לבד מהתנגדות הנציגות (באמצעות מר קוזי) הוגשו גם התנגדויות פרטניות של בעלי דירות, אשר אף התייצבו לדיון.

זאת ועוד. כפי שכבר פסקתי בתיק 309/10 מאיר כהן נ' עזרא כדורי (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים) אין די בהסכמת הנציגות לביצוע עבודות ברכוש המשותף כתחליף להסכמה קניינית של בעלי הדירות, וממילא אין בסמכות הנציגות ליתן הסכמות כנ"ל.

50. שביעית, אין כל קשר בין הליכי התכנון לבין ההליכים הקשורים בסוגיות הקנייניות - בעוד הליכי התכנון נדונים בהתאם לדיני התכנון והבניה ובפני רשויות התכנון על שלוחותיהן השונות, הרי שהסוגיות הקנייניות נדונות על פי דיני המקרקעין ובפני הערכאות המוסמכות. הפרדה ברורה ישנה בדינים החלים, בהסכמות הנדרשות ובזכויות המתנגדים. אפילו השיקולים באם לאשר בקשה לבניה או לקבל התנגדות לה שונים בשתי מערכות הדינים.

אין גם הכרח לזהות בעמדת בעל דירה בכל אחד מההליכים - בעל דירה יכול להתנגד תכנונית לבקשה להיתר אך להסכים קניינית לביצוע הבנייה ולהיפך. הדין אינו מכיר ב"קשירה" החד ערכית שמבקשים הנתבעים לעשות בין הליכי התכנון להסכמות הקנייניות הנדרשות על פי הדין. לפיכך, אף אם התקבלה החלטה תכנונית בהסכמת בעלי הדירות (כטענת הנתבעים) אין הדבר מבסס אוטומטית הסכמה קניינית לביצוע אותן העבודות, ודאי לא בנסיבות הפרטניות של התובעים כפי שפורטו לעיל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הסכמת מר דנוס

51. אין מחלוקת כי מר דנוס חתם על הבקשה להיתר בניה. אין גם מחלוקת כי בשלב מאוחר יותר מר דנוס חזר בו מהסכמתו זו בהודעתו לעירייה (עמוד 20 שורות 19-20). משעה שהגיש מר דנוס התנגדות, עוד לפני מתן היתר הבניה, ואף התייצב לדיון בהתנגדויות (עמוד 20 שורות 25-26), לא ניתן היה לראות עוד בחתימתו הראשונית על הבקשה להיתר (זמן רב קודם לכן) כהסכמה קניינית הנדרשת בהתאם להוראות תיקון 18. בנסיבות אלו, אף שמר דנוס לא הודיע לנתבעים ישירות על ביטול הסכמתו (עמוד 20 שורה 24), הרי משעה שהיתה ידועה להם התנגדותו לתוכנית (והרי גם הם ובא כוחם נכחו בדיון ההתנגדויות) לא יכולים היו הם עוד להסתמך באופן מוחלט ובלתי חוזר על חתימתו הקודמת במסגרת ההליך התכנוני.

52. מר דנוס גם הציג בעדותו טעם ענייני לביטול חתימתו והסבר בנוגע למועד חזרתו בו מההסכמה - "בהתחלה חתמתי לאלון לפני כמה שנים. אחרי שהגיע מכתב מהעירייה לגבי תמ"א 38 והסיכון אפילו אפסי שזה יכול לפגוע בנכס שלי חזרתי בי ושלחתי מכתב לעירייה. ש.ת. החזרה שלי הייתה הרבה לפני שהוא התחיל לבנות. זה היה לפני כמה שנים. אני לא זוכר בדיוק את התאריך" (עמוד 20 שורות 19-22) ובהמשך "קודם כל זכותי הלגיטימית להתנגד. כשחתמתי פעם ראשונה לא ידעתי שיש לי זכות קניינית במקום הזה. דבר שני, הבניין רעוע בצורה מחרידה. דברים נופלים מהקירות. הקירות מתפוררים. יש נזילות בכל מקום, סדקים. אני לא מוכן לקחת את הסיכון שהבניין יקרוס" (עמוד 21 שורות 5-7).

53. ודאי אמורים הדברים כאשר מכתב העירייה "מזמין" את בעלי הדירות לשוב ולבחון את הסכמתם (במישור התכנוני) – "מצאנו לנכון להביא לידיעתכם עובדה זו ונבקשכם להודיע בכתב למזכיר הועדה המקומית, אם הסכמתכם לבניה על הגג עדיין בתוקף" (ר' נספח 2 לתצהיר ענפי).

54. הדברים האמורים הינם למעלה מן הצורך מאחר וממילא, כאמור, נקבע כי אין ביד הנתבעים הסכמת התובעים בהליך דנן.

סיכום ביניים

55. לאור האמור יוצא כי בידי הנתבעים, לכל היותר, הסכמה של 8 (למצער 7 אם נאשר את חזרתו של מר דנוס מהסכמתו כאמור) מתוך 12 בעלי דירות בבית לביצוע עבודות הבניה, הסכמה שאין בה די בהתאם להוראות החוק כאמור.

56. לפני סיום פרק זה אציין כי לאור העובדה שהבית דנן נרשם בפנקס ביחד עם שני בתים נוספים, ללא כל הפרדה ניהולית, קניינית או אחרת במסמכי הרישום, הרי שבהתאם להוראות הדין ההסכמה הנדרשת לביצוע הבנייה הינה של 3/4 מתוך כלל 48 בעלי הדירות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בשלושת המבנים הרשומים יחדיו כבית משותף אחד. הסכמה שכזו לא נטען כלל כי יש בידי הנתבעים וממילא אישרה הנתבעת בעדותה כי היא לא קיימת (עמוד 39 שורה 28).

תום לב

57. כפי שכבר פסקתי בהרחבה במסגרת תיק 186/12 מתי ולטר ואח' נ' אהרון ישראלי ואח' (פורסם בנבו ובאתר משרד המשפטים) והדברים נכונים גם כאן, משלא התקיים רף ההסכמה המינימלי שנקבע בדיון, אין הנתבעים יכולים לחסות בצילו של תיקון 18. די בכך להביא לקבלת התביעה בכל הקשור להרחבת דירת הנתבעים לחלל הגג. אולם, למען שלמות התמונה נכון יהיה להבהיר כי ממילא גם שיקולי תום הלב עומדים לצד התובעים.

58. ראשית, הנתבע מלין על כי התובעים לא פנו אליו להביע את התנגדותם (סעיף 39-41 לתצהיר). דא עקא, אין כל הסבר מדוע הנתבעים לא פנו לבעלי הדירות האחרים לקבלת הסכמתם המפורשת, לפני מועד הדיון בהתנגדויות ובודאי שלאחריו. על הנתבעים החובה לקבל הסכמות מפורשות לבניה המבוקשת אך הם חדלו מלעשות כן ופעלו מאחורי גבם של בעלי הדירות המתנגדים, ודאי אמורים הדברים כאשר הנתבעים מסוכסכים עם חלק מבעלי הדירות (התובעים 3, 4 ו-5 כאמור לעיל) וכאשר הנתבעים היו מיוצגים כל העת.

59. לזאת יש להוסיף כי גם הסכמות קנייניות של בעלי הדירות האחרים, במועדים הרלבנטיים להליכי התכנון, הדיון בהתנגדויות ועד תחילת הבנייה, לא היו ברורות וחד משמעיות והינן מוטלות בספק. ודאי אמורים הדברים בנוגע למר אסף ערב, שבדומה למר דנוס חזר בו מהסכמתו המקורית לבקשה עוד במהלך הליכי הרישוי (ר' סעיפים 12-13 לסיכומי התובעים), ומשפחת שרעבי שגם את הסכמתה אין בידי הנתבעים (עמוד 39 שורה 8). רק בדיעבד (אחרי הגשת תביעה זו) קיבלו הנתבעים הסכמות מפורשות של מספר בעלי דירות בבית (ר' נספחים 34-37 לתצהיר הנתבע). למעשה, הנתבעים נקטו פעולות קנייניות חד צדדיות בהסכמת בעלי דירות ספורים בלבד (אם בכלל) - מדובר בהתנהגות חסרת תום לב מצד בעלי דירה בבית משותף.

60. שנית, על אחת כמה וכמה אמורים הדברים כאשר בין הצדדים כבר התנהלו הליכים משפטיים בנוגע לשימוש בגג, וידוע ומוסכם, לרבות בפסק דין חלוט, מעמדו של חלק זה בבית כרכוש משותף (תיק 50/13). למעשה, התנהלות ראוייה מצד הנתבעים היתה מביאה לכך שכבר במועד הדיון בהליך הקודם היו צריכים הם לחשוף את כוונת ולעמוד על רצונם לבצע ההרחבה המבוקשת. כבר אז צריכים היו הם לקבל את ההסכמות הקנייניות הנדרשות מבעלי הדירות.

61. שלישית, התובעים העלו נימוקים להתנגדותם לבניה המבוקשת - פגיעה באפשרות ביצוע פרויקט תמ"א 38 או פינוי בינוי (תכנונית וקניינית), חשש לפגיעה ביציבות במבנה כתוצאה מההרחבה המבוקשת ופגיעה בזכויות קנייניות - תשלום דמי איוון (ר' עדות ענפי עמוד 12 שורות 21-22, עדות עו"ד ירון בעמוד 16 שורות 23-27 ובהמשך עמוד 17 שורות 19-26, עדות גלברג בעמוד 23 שורות 8-12, עדות זריהן בעמוד 30 שורות 26-27 וחוות דעת המומחה טרכטנברג).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם על פי הגישה המקילה ביותר עם הנתבעים (ר' סקירה בהרחבה בהקשר זה בפרשת ולטר לעיל) מדובר בנימוקי התנגדות ראויים ומספיקים שממילא המפקח אינו נדרש לבחון לגופם.

62. בהקשר זה נכון יהיה להבהיר כי הוכחה בפני, למעשה, פגיעה קניינית בבעלי הדירות בבית כתוצאה מהבניה המתוכננת, הן בהרחבה לחלל הגג והן בחיזוק החדר בדירת הנתבעים, ולכך עוד נשוב להלן.

63. רביעית, אין ממש בטענה כי מדובר הליך ערעור על הליכי התכנון - טענות התובעים שבפני הינן טענות קנייניות גרידא. כך, הטענה בדבר העדר הסכמה קניינית להצמדת חלל הגג וזכויות הבניה. כך, הטענה בדבר פגיעה באפשרות ביצוע פרויקט תמ"א 38 (ר' בקשר זה עדות גלברג בעמוד 23 שורות 8-12). כך, הטענה בדבר החשש מפגיעה ביציבות הבית וכפועל יוצא גם פגיעה באפשרות בעלי הדירות האחרים לבצע עבודות דומות בדירתם.

כידוע, אף אם מאושרת בניה מבוקשת מבחינה תכנונית, אין הכרח כי היא תאושר קניינית, ולהפך, ודאי כאשר כל רשות מוסמכת בעניינים מהותיים שונים.

64. חמישית, אומנם קיים סכסוך שונה ונפרד בין הנתבעים לבין חלק מהתובעים. אולם, לא מצאתי כי לסכסוך זה תרומה מרכזית בהתנגדות התובעים לבנייה המבוקשת לעומת טענותיהם האחרות כמפורט לעיל.

65. שישית, לא הוצע כל הסבר מצד הנתבעים מדוע המתינו חודשים רבים מאז דחיית ההתנגדויות (בחודש 03/13 עפ"י נספח 5 לתצהיר הנתבע) ועד להוצאת היתר הבניה ותחילת הבניה בפועל שבועות בודדים לאחר מכן (חודשים ינואר-פברואר 2014), כל זאת מבלי להודיע לבעלי הדירות בבית דבר, לא בהיבט התכנוני (בדבר הוצאת ההיתר) ולא בהיבט הקנייני (בדבר התחלת הבניה). למעשה, מעדות שיף כמצוטט לעיל עולה הסתרה של עבודות הבניה (להבדיל מעבודות שיפוץ בדירת הנתבעים). התנהלות זו איננה אלא חלק מניסיון של הנתבעים, בחוסר תום לב, ליצור "עובדות בשטח" ללא הסכמת הרוב הנדרש.

66. שביעית, למעשה, גם הנתבעת מודעת לכך כי התנהלות הנתבעים הייתה שגויה (עמוד 40 שורות 3-7). בין אם זו נבעה מחוסר תום לב, עצימת עיניים או למצער תמימות, הרי שאין בכך לסייע בידם בהעדר הסכמה כנדרש לביצוע העבודות. בין כך ובין בכך, אין מדובר במקרה נדיר וחריג המצדיק שלא להיעתר לתביעה שמטרתה להגן על זכות קניין (ר' רע"א 6339/97 משה רוקר ואח' נ. משה סלומון ואח' פד"י נ"ה(1) 199 והעקרונות שנקבעו שם בעניין זה).

ראוי לאזכר בהקשר זה גם את דבריו של כבוד הנשיא אולשן בע"א 281/61 משה שלוסר נ. יעקב כץ, פד"י ט"ו(3) 239 "אין אדם יכול לדרוש זכות הנאה כלשהי מרכושו של הזולת רק מפני שנח לו הדבר, או מפני שהוא זקוק לזה ולזולת אין הדבר גורם כל נזק שהוא – אפילו מצבו הקשה של האדם הזה עשוי לעורר אהדה אליו מצד בני אדם. אין לזהות



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

שיקולים שביושר במשמעות המשפטית, דבר התלוי ברצונו הטוב של הזולת, אין לכפות עליו "רצון טוב" זה על ידי החלת שיקולים שביושר. עוד לא שמענו על הלכה מעין זו".

פגיעה קניינית כתוצאה מהבנייה

67. לאחר ששקלתי בכובד ראש את טענות הצדדים והראיות שהוגשו בהקשר זה מצאתי גם כי יש בבנייה המבוקשת משום פגיעה של ממש בזכויות הקניין של התובעים בשלושה מישורים – חשש ליציבות המבנה, פגיעה בזכות בעלי הדירות האחרים לבנות ופגיעה באפשרות מימוש פרויקט תמ"א 38.

חשש ליציבות המבנה

68. בכל הקשור לסוגיית יציבות המבנה הובאו בפני חוות דעת מקצועיות מטעם הצדדים. במאזן ההסתברויות מצאתי להעדיף את חוות דעתו של מר טרכטנברג על פני זו של מר שפירא ובהתאם לקבוע כי לא הוכח שאין בבניה המבוקשת כדי לסכן את יציבות המבנה (עמוד 7 שורות 3-8). עצם קיומו של ספק בהקשר זה, די בו כדי לבסס פגיעה קניינית בתובעים.

69. ראשית, מר שפירא הינו מתכנן השלד להיתר הבניה המבוקש (עמוד 33 שורה 14). משכך, ברור כי בחוות דעתו יאשר את אותן הבדיקות והעבודות המבוצעות בפועל על פי אישורו, באחריותו ובחתימתו (עמוד 34 שורה 5). ודאי אמורים הדברים כאשר הוכח בפני כי רשות הרישוי מסתמכת על חישובים סטטיים מצד מגיש הבקשה בלבד, הוא מר שפירא בנסיבות דנן, ללא בדיקה נוספת - "באופן סדיר העירייה לא בודקת האם החישובים הסטטיים נכונים או תואמים היא מסתפקת בלראות שיש מסמך והיא מקבלת את המסמך כמו הוא. לכן מהנדס העיר לא יודע אם החישובים נכונים אני מניח שהוא מסתמך על הצהרה של אותו מהנדס שחם עליה. רק על תכניות תמ"א 38 קיים הליך שהעירייה מעבירה לגורם חוץ מקצועי לבדוק את החישובים הסטטיים. כל יתר המקרים מסתפקת בהצהרת המהנדס" (עמוד 6 שורות 11-15).

מסיבות השמורות עימם בחרו הנתבעים להביא לעדות בפני מומחה אשר מעורב בדבר. מאידך, לא מצאתי דבר בטענות הנתבעים לעניין מומחיות מר טרכטנברג - לא בהיבט המקצועי (עמוד 6 שורות 16-19) ולא בהיבט משוא הפנים (ר' עמוד 5 שורות 18-25 ועדות מר גלברג עמוד 24 שורות 6-9).

70. שנית, הוכח כי החישובים הסטטיים המקוריים שהוגשו ביחד עם הבקשה להיתר ממילא אינם עדכניים עוד, בין היתר, לאור שינוי מתוכנן של מיקום החדר המחוזק וכן הבדלים שבין החישובים הסטטיים שהוגשו לבין הבקשה להיתר (עמוד 34 שורות 29-30 ועמוד 35 שורה 5). למעשה, לא הוצגו כלל חישובים סטטיים עדכניים - לא בפני ואף לא בפני רשויות התכנון במסגרת תיק הרישוי (עמוד 34 שורה 6). על העבודות גם הוטל צו הפסקה שיפוטי לאור השינויים המבוקשים (ר' מוצג ת/2 וכן עמוד 33 שורות 26-28).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

71. שלישית, לא בוצעו בדיקות קרקע וגם לא נבדקו חישובים סטטיים מקוריים ממועד הקמת הבית (עמוד 35 שורות 12-13 ו-17). זאת ועוד. אף שלכאורה נטען כי בוצעו בדיקות ליסודות (במהלך ביצוע העבודות) הרי שאלו לא הוצגו בפניי וגם אינם קיימים בתיק הרישוי (עמוד 35 שורות 21-23). בנסיבות אלו הסתמכות על הוספת משקלים סטטיסטית (באחוזים מסך המשקלים הקיימים) איננה מספקת, ודאי כאשר המשקלים המתווספים ומיקומם אינם עדכניים (על פי החישובים שהוגשו במסגרת הבקשה להיתר). יש גם לזכור קיומה של מחלוקת בין הצדדים בנוגע להיקף המשקלים המתווספים וכפועל יוצא (אף לפי שיטת מר שפירא) משמעותם (ר' עדות טרכטנברג להלן כנגד עדות שפירא עמוד 34 שורות 21-23).

72. רביעית, נותרה ללא מענה עדותו של המומחה טרכטנברג כי הבנייה המתוכננת מנוגדת לתקן - "אני כתבתי מה שכתבתי שעל פי מסמכים שהוגשו לעירייה בתיק הכחול החישובים הסטטיים לא כללו את כל הבדיקות הנדרשות העומסים המעוברים על היסודות לא נבדרה הזרימה שלהם לפי החישובים הסטטיים נוספים 200 טון עומס. לא נערכה בדיקה של היציבות האופקית של הבניין והמסקנה של כל זה שזה בניגוד לתקנים. ש.ת. אני חושב שלבנות בניגוד לתקן זה מהותי וקריטי. אתה פרשנות מקלה על עבירות על החוק" (עמוד 7 שורות 24-28).

פגיעה קניינית בזכות התובעים לבנייה

73. עדותו של מר שפירא (מטעם הנתבעים) מבססת, למעשה, פגיעה משמעותית בתובעים כתוצאה מפעולות הבניה המתוכננות. ובמה דברים אמורים.

74. מר שפירא מבססת את חוות דעתו על אפשרות הבניה והחזיק בדירת הנתבעים על חישוב הוספת עומסים סבירים לביסוס הקיים – "סעיף 1.1 ד.למוצג ת/3 ע"מ 1 יש לנו בניין שעומד 50 שנה. יש קרקע שאם השנים היא מצטופפת והתסכולת שלה גדלה. לפיכך אם אני מוסיף טיפה עומס ואני מגלה שהעומס הזה הוא לא יותר מאשר 10/5% שקיים היום דה פקטו בבניין מבחינתי זה תקין" (עמוד 35 שורות 14-16). ויוער, בשל שיטת בדיקה זו סבור המומחה שפירא כי לא נדרשות בדיקות קרקע (בניגוד לדעתו המקצועית של טרכטנברג).

בהמשך מעיד מר שפירא כי "הכל תלוי בכמה אתה מעמיס ביחס למה שקיים היום. אם אני מעמיס על בניין ששוקל 100 טון יש הבדל אם אני מעמיס על ששוקל 100 טון קצת זה לא משמעותי. ברמת הביסוס כן, במבנה שלוט כמו המבנה הזה" (עמוד 35 שורות 18-20).

75. משמעות העדות כאמור הינה כי חיזוק החדר בדירת הנתבעים והרחבת דירתם לחלל גג הבית מונעים, למעשה, ביצוע חיזוק חדר דומה בדירות האחרות בבית, ולכאורה גם כל עבודת שיפוץ אחרת בדירות האחרות בבית שיש בה משום העמסת משקלים נוספים. כך גם מאשר במפורש מר שפירא בעדותו - "על הבניין דהיום אני אבקש חיזוק יסודות כדי שכל הדירות יעשו חדר מחוזק. נדרש חיזוק של האגף" (עמוד 36 שורות 3-12). יוצא אם כן כי אישור העבודות בדירת הנתבעים משמען הגבלה על אפשרות בעלי הדירות האחרים לבצע



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

גם הם עבודות מקבילות (חיזוק חדר בדירתם) או עבודות אחרות בדירתם להם משמעות משקלית. אין כל הצדק, בהעדר רוב נדרש של בעלי הדירות בבית (שגם הוא חריג לדיני הקניין הרגילים כאמור) מדוע דווקא הנתבעים יהיו היחידים אשר ייהנו מחדר מחוזק בבית, תוך ניצול יסודותיו הקיימים של הבית (במלואם), ללא נשיאה בעלויות החיזוק הכלליות הנדרשות לשם כך. דומה הדבר לפגיעה קניינית בבעלי דירות בבית כתוצאה מהרחבה שמשמעותה ניצול כל השטחים המשותפים בבית או מלוא זכויות הבניה הקיימות.

76. בנסיבות אלו, לאור החשש ליציבות ולסדיקה ולאור הפגיעה הקניינית האמורה יש מקום לאסור גם על חיזוק החדר המבוקש בדירת הנתבעים על פי ההיתר הקיים בהתאם להוראות סעיפים 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי.

פגיעה באפשרות ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית

77. לבד מכך שעצם אישור הבניה בדירת הנתבעים יהווה עבורם תמריץ שלילי להשתתף או לתת הסכמתם לביצוע פרויקט על פי תמ"א 38 בבית (על פי כל אחת מחלופותיו, ודאי בנוגע לחלופה על פי תיקון 2 לתמ"א או פרויקט פינוי בינוי), הרי שהוכח כי יש בעצם הבניה הפרעה למימוש פרויקט שכזה.

78. מכתב העירייה לבעלי הדירות ולפיו "בניית חדר היציאה לגג תקטין משמעותית את הסיכוי לבנות בבניין שלכם מכח תמ"א 38" (נספח 2 לתצהיר ענפי) לא נסתר. בהקשר זה לא הובאה מטעם הנתבעים כל עדות שבמומחיות או תעודת עובד ציבור של נציג מוסמך במינהל ההנדסה בעירייה אשר היה בה להבהיר את האמור במפורש במכתב זה.

79. למעשה, גם החלטת הועדה מיום 31.07.12, מחזקת את האמור, שהרי הליך ההיתר הוקפא לפרק זמן של 6 חודשים לטובת הגשת בקשה להיתר מכח תמ"א 38 (מוצג נ/1).

80. הוכח בפני כי הליכים למימוש פרויקט פינוי בינוי וחילופין תמ"א 38 עודם מתנהלים (עמוד 12 שורות 10-19).

שיהוי

81. אין בידי להיעתר לטענות הנתבעים לעניין שיהוי לכאורה בנקיטת ההליכים על ידי התובעים (ר' לעניין טענת השיהוי ע"א 6805/99 תלמוד תורה הכללי והישיבה הגדולה עץ חיים בירושלים נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים פ"ד נז(5) 433; ע"א 410/87 עזבון ליברמן נ' יונגר פ"ד מה(3) 749, 755-756; רע"א 8630/05 ניר שיתופי – אגודה ארצית להתיישבות עובדים עבריים בישראל בע"מ ואח' נ' עיריית הוד השרון (טרם פורסם)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

82. ראשית, אני דוחה את טענת הנתבעים כי אין מדובר בהליך הראוי אשר ננקט על ידי התובעים. בהקשר זה כבר התייחסנו לעיל - ההליך הינו קנייני, מראשיתו ועד אחריתו, ואינו דין כלל במערכת הדינים והשיקולים התכנוניים.

83. שנית, כל הטענות בדבר אי פניה של התובעים לנתבעים והתנהגות הצדדים כבר נדונה בפרק "תום הלב" לעיל והוכרעה - דווקא הנתבעים היו אלה אשר נהגו בחוסר תום לב ולמצער בעצימת עיניים. ודאי כאשר אין לנתבעים כל קשר (חלק משמעותי ביוזמתם הם) עם התובעים 1 עד 5 (ר' דיון בפרק בחינת ההסכמות לעיל).

84. שלישית, אף שהליכי הרישוי ארכו מספר שנים, לא היתה מוטלת על התובעים חובה לנקוט בהליכים דנן קודם למועד בו נקטו בהם, בסמוך ממש לאחר תחילת עבודות הבניה - תחילת פברואר 2014 (עמוד 36 שורה 27). הוכח גם כי רק במועד זה נודע לתובעים דבר הוצאתו של היתר הבניה זמן קצר קודם לכן וכוונת הנתבעים לבצע עבודות הרחבה להבדיל משיפוץ דירתם בלבד (עמוד 27 שורות 1-3 ו- 20-22 ועמוד 36 שורות 25-26).

הצפייה הסבירה של כל בעל דירה היא כי המבקש לעשות שימוש ברכוש משותף בבית, ודאי זה המבקש להרחיב את דירתו לחלל גג משותף שנקבע בפסק דין חלוט מעמדו, יקבל את הסכמת בעלי הדירות (בהיבט הקנייני), אף אם בידו היתר תכנוני. כך גם סברו התובעים דנן (עמוד 13 שורות 1-9 ועמוד 15 שורות 11-12).

בהקשר זה אין גם כל הצדקה בחיוב המתנגדים לבניה ברכוש המשותף לנקוט בהליכים עוד לפני קבלת היתר בניה, שהרי אפשר והליכי הרישוי והתכנון יסתמו את הגולל על הבניה המבוקשת, ודאי כאשר הנטל להוכיח קיומה של הסכמה קניינית לביצוע הבנייה מוטל על שכם הנתבעים כאמור.

85. רביעית, בנסיבות האמורות אין כל שימוש לרעה בזכות התובעים, זניחה של תביעתם וגם לא כל צפייה לגיטימית ראויה להגנה של הנתבעים לביצוע עבודות בנייה ברכוש המשותף. ויוזכר, כבר התקיים דיון משפטי בנוגע לגג, בידי הנתבעים לא היו מעולם הסכמות מפורשות לבנייה והצדדים מצויים בסכסוך מתמשך. כל אלו לא יכולים היו לבסס צפייה כלשהי של הנתבעים, ודאי לאור בחינת תום הלב והתנהלות הצדדים כאמור לעיל.

סיכום

86. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה וקובע כלהלן:

87. ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע כל עבודות בניה ו/או הריסה ברכוש המשותף בבית ברחוב אשרמן 17 תל אביב הבנוי על חלקה 39 בגוש 6163, לרבות, בגג הבית ובחלל גג הרעפים, לרבות על פי היתר בניה מספר 13-1585, כל עוד לא התקבלה בידם הסכמה מפורשת כדין של רוב בעלי דירות בבית בהתאם להוראות חוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 97/14

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

88. על הנתבעים להשיב על חשבונם את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, עובר לתחילת ביצוע העבודות על ידם, וזאת בתוך 30 יום מהיום, באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים.

89. ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לבצע עבודות לשיפור מיגון, חיזוק חדר או הפיכת חדר קיים בדירתם לממ"ד, לרבות על פי היתר בניה מספר 13-1585.

90. מובהר כי לבד מן האמור רשאים הנתבעים לעשות כל עבודות שיפון אחרות בדירתם.

91. בנוסף לאמור לעיל יישאו הנתבעים בהוצאות ניהול ההליך כלהלן:

92. הנתבעים ישלמו לתובעים סך של 657 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 18.02.14, ועד למועד התשלום בפועל.

93. הנתבעים ישיבו לתובעים את עלות חוות דעת המומחה טרכטנברג וזאת בתוך 7 ימים מהמצאת חשבונית מס בגין עלות חוות הדעת ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום המצאת החשבונית ועד למועד התשלום בפועל.

94. הנתבעים ישלמו לתובעים בגין החזר הוצאות שכ"ט סך של 13,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

95. בפסיקת גובה החזר הוצאות שכ"ט התחשבתי בתוצאות ההליך, בכך שהתקיימו 3 ישיבות בית משפט והוגשו תצהירים וסיכומים בכתב.

96. בנוסף לאמור על הנתבעים לשאת גם בתשלום הוצאות הבקשה לצו מניעה זמני בתיק בקשה 98/14 בסך של 5,000 ₪ כפי שנקבע בהחלטתי מיום 27.02.14 בתיק הבקשה.

97. לאור תוצאות ניהול ההליך אני מורה על השבת הערבויות הבנקאיות שהופקדו אצל חשב משרד המשפטים בהתאם להחלטתי מיום 27.02.14 לידי התובעים.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום ט"ז שבט תשע"ה, 05 פברואר 2015, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב